

1528543-02.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... afastada a desclassificação do delito de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Caracterizada, portanto, a infração penal de tráfico de drogas, passo a dosimetria da pena.

O réu é reincidente, de acordo com a certidão de fls. 61/64.

Considerando que foi condenado definitivamente, por duas vezes, pelo delito de roubo majorado, (Autos nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1528543-02.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1528543-02.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIAN PAULO MIRANDA EVARISTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

GIAN PAULO MIRANDA EVARISTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo apurado, no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 16h55min, no Largo do Arouche, altura do nº 50, República, nesta Capital, trazia consigo, para fim de tráfico, 13 (treze) porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida, o réu foi citado e notificado, e apresentou resposta à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidos dois policiais e o réu foi interrogado. Encerrada a instrução criminal, em suas alegações, o Ministério Público buscou a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa requereu a absolvição do réu por insuficiência probatória para a condenação. Subsidiariamente pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o crime previsto no art. 28 da Lei de drogas, e também por sua absolvição diante da atipicidade da conduta, ou ainda em caso de eventual condenação, a fixação da pena base no mínimo legal estabelecido, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, o reconhecimento do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da lei 11.343/06, e o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão das drogas, laudo de constatação de substância entorpecente, laudo de exame químico toxicológico positivo para cocaína, (fls. 76/78), relatório final da autoridade policial, bem como pela robusta prova produzida na fase investigativa e em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria também é inconteste.

Com efeito, os dois policiais civis Eduardo Keith Hirose e Emerson Rocha dos Santos, em juízo, após prestarem o compromisso de dizer a verdade, relataram que estavam em diligências pelo Largo do Arouche, local conhecido pela venda de entorpecentes.

Para tanto, estacionaram a viatura descaracterizada e ficaram observando a movimentação das pessoas, e puderam visualizar um indivíduo se aproximar do réu, com notas de dinheiro em mãos, lhe entregar o valor e receber algo em troca. Permaneceram no local por alguns minutos e assim presenciaram outra pessoa também se aproximar de Gian em novo ato típico de venda de entorpecentes e diante disso, resolveram abordá-lo, o réu ainda tentou fugir mas, como estava com uma das pernas quebrada, acabou sendo preso e ao ser revistado, com ele foram encontrados cocaína e dinheiro.

Diante disso, Gian foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia onde foi constatado que também era, ainda, foragido da justiça.

Ao ser interrogado em juízo, o réu Gian Paulo Miranda Evaristo, afirmou que estava com R\$ 40,00 no bolso e passou na região central da cidade para comprar entorpecentes e foi abordado pelos policiais. Chegou a indicar-lhes quem seria o traficante, mas como os policiais não o encontraram eles atravessaram a rua, encontraram algumas porções de droga no chão e voltaram ao local em que estava e o prenderam. Afirmou, que de fato, foi visto pelos policiais em duas oportunidades conversando com uma pessoa, já que ao chegar para comprar a droga, o traficante não tinha troco e por isso, foi à padaria, comprou cigarros e retornou para comprar o entorpecente, sendo preso em seguida.

Por fim disse que realmente estava foragido da colônia penal, já que logo que foi beneficiado com o regime semiaberto, tomou conhecimento da morte de seu irmão e resolveu fugir para ir ao enterro.

Estas são as provas colhidas nos autos e diante delas, ao contrário do alegado pela Defesa, a condenação do acusado é medida que se impõe.

De início, observa-se que a quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento, o local em que o réu se encontrava, já conhecido como ponto de drogas e os depoimentos dos policiais, no sentido de que visualizaram, por duas vezes atos de comércio de drogas, não deixam dúvidas da ocorrência do crime.

A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado:

PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induzem à certeza de destinação ao comércio - Recurso não provido. (Relator: Lustosa Goulart - Apelação Criminal n.º 159.552-3 - São Paulo - 05.05.94).

Veja-se ademais, que os dois policiais foram uníssomos em afirmar que de dentro da viatura descaracterizada puderam observar o réu por duas vezes, vendendo entorpecentes.

Neste ponto, o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas. Imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são policiais

aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos.

Ressalte-se que não há nos autos indício que qualquer tipo de perseguição pelos policiais contra o acusado.

Nesse sentido:

“Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos sem geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição” (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Outrossim, a versão apresentada pelo acusado se mostra fantasiosa e isolada nos autos, já que não apresentou qualquer prova que à comprovasse, devendo neste ponto, também ser afastada a desclassificação do delito de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Caracterizada, portanto, a infração penal de tráfico de drogas, passo a dosimetria da pena.

O réu é reincidente, de acordo com a certidão de fls. 61/64.

Considerando que foi condenado definitivamente, por duas vezes, pelo delito de roubo majorado, (Autos nº 0005793-37.2018.8.26.0050 e autos nº 0061141-16.2013.826.0050), a primeira condenação será considerada na segunda fase da dosimetria da pena.

Já a outra condenação, cuja pena foi extinta, será considerada com como Maus Antecedentes, o que nos permite aumentar a pena base em 1/6, chegando-se ao patamar de 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Não há que se falar em desconsideração da condenação acima apontada apenas e tão somente pelo decurso do tempo já transcorrido, já que, se por um lado elas não podem mais serem consideradas como agravantes em razão do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, fato é que nada impede de considerá-la como Maus Antecedentes, já que demonstra a personalidade criminosa do acusado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

STJ- “condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de Maus Antecedentes” (HC 456891/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.10.2018).

E ainda, conforme precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, “não constitui ilegalidade o fato da sentença considerar os antecedentes criminais e outras circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, aumentando, depois, a pena base, em razão da reincidência” (HC nº 1.990, Rel. Min. Carlos Veloso, DJU de 22.09.95, p. 30.591).

“Apesar de desaparecer a condição de reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é como um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo, por exemplo, como antecedente criminal” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).

Na segunda fase, há que se considerar a agravante da reincidência e ainda que o crime foi praticado, em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que até a presente data ainda assola o país por conta do coronavírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020, que infelizmente vem fazendo inúmeras mortes. Neste ponto, não obstante as alegações da Defesa, e respeitadas posições em contrário, para este juízo, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal. Desse modo, agravo

a pena em 1/5 (um quinto), alcançando o patamar de 07 anos de reclusão e 699 dias-multa.

Neste sentido, já se manifestaram nossos Tribunais como a seguir se demonstra:

“Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos” (TJ-SP – PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

E ainda: “(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência” (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

“Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias.” (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

“O acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença”, escreveu o magistrado em seu voto. “De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. (4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Autos nº 1509419-67.2020).

“O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a

incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), "a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida com calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda" (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander). Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

Na terceira fase da dosimetria, mostra-se incabível o reconhecimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, já que ao contrário do alegado pela Defesa, há nos autos provas de que o réu se dedica a prática de atos criminais, posto que já condenado por mais de uma ocasião, além de ser reincidente.

Nesse particular, não há falar em bis in idem pelo simples fato de a reincidência servir agora como fundamento para agravar a pena e também impedir a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, não se vislumbrando, por aqui, qualquer inconstitucionalidade.

Isto porque, "...na aplicação do preceito em foco, o Juiz há de verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena, não se podendo falar em bis in idem por ter sido a reincidência considerada para aumentar as sanções e também impedir a incidência do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, pois a aplicação de tal dispositivo exige a ocorrência simultânea de todas as Condições mencionadas, ou seja, ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização criminosa, o que não é o caso do acusado.

Conforme já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, "não há que se falar em bis in idem mas sim em cumprimento dos efeitos lógicos, legalmente previstos, decorrentes de um mesmo instituto jurídico a reincidência quando foi agravada a sanção do paciente na segunda etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da agravante do art. 61 do CP, e deixou-se de fazer incidir a causa especial de diminuição da pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da não primariedade do paciente" (HC 118403/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 15.12.2009)." (TJSP, Apel. Crim. nº 990.10.184009-0, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro).

Além disso, "O agravamento da pena pela reincidência também está correto e decorre de expressa determinação legal. Não ocorreu bis in idem. Não é raro que uma mesma circunstância reflita em mais de uma direção. O reincidente, v.g., não tem direito a sursis, por expressa disposição legal. Não obstante, o magistrado é obrigado a

exacerbar sua pena, porque a reincidência também é agravante. Seguindo o mesmo raciocínio, no caso ora em exame, não aplicável a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, dada a recidiva, a qual também é usada para agravar a pena, por determinação legal.” (Rev. Crim. nº 990.09.160794-0, 6º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Eduardo Pereira).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça não se afasta dessa conclusão: “Não há que se falar em bis in idem na utilização da reincidência para agravar a pena e para afastar a aplicação da minorante contida no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, visto que, consoante a uníssona jurisprudência desta Corte, é possível que um mesmo instituto jurídico incida em momentos distintos da dosimetria da pena, desde que haja comando legal específico nesse sentido. Precedentes.” (HC 202.163/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 16/04/2013, DJe 24/04/2013).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos de reclusão e 699 dias- multa, que se fixa no mínimo legal estabelecido, já que não há nos autos provas da condição econômica do acusado

Nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, e a ainda em razão de sua reincidência, o regime inicial para o cumprimento da pena será o fechado.

Veja-se que o réu estava em cumprimento de pena em regime semiaberto e ao ser beneficiado fugiu da prisão e solto se viu na prática do crime de tráfico, delito este causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. Por tais, fatos, demonstrou que somente o cárcere lhe é suficiente.

Outrossim, levando-se em conta a quantidade de pena aplicada e a sua reincidência, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do que dispõe o art. 44, incisos II e III, do Código Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, e para a garantia da aplicação da lei penal. Como se sabe o crime de tráfico é o que sustenta inúmeras facções criminosas que com o dinheiro arrecado pela venda de drogas adquirem armamento de alto calibre e praticam diversos outros delitos colocando em risco toda a sociedade.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Assim, não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do Código Processual Penal, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Determino ainda, se o caso, destruição de toda droga apreendida, inclusive eventual quantia guardada para contraprova, nos termos legais.

Por fim, declaro a perda dos valores apreendidos em favor da União nos termos do art. 63, da Lei de Tóxicos

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2022.